

1500657-69.2020.8.26.0452

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Piraju

Foro: Foro de Piraju

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... forte estímulo para a prática do tráfico de drogas. Noutro giro, por mais que seja verdade que a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal não venha surtindo o efeito desejado, nem por isso se pode cogitar da possibilidade de renunciarmos à tutela do direito penal para coibir tal conduta. Fosse assim, condutas delituosas diversas como homicídios, latrocínios e roubos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piraju

Foro de Piraju

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 13 de Maio, 476, ., Centro - CEP 18800-000, Fone: (14)3351-2139, Piraju-SP - E-mail: pirajupec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500657-69.2020.8.26.0452

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3079864/2020 - DEL.POL.SARUTAIA, 13878567 - DEL.POL.SARUTAIA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

GUILHERME AFONSO DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

29/06/2022

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 29/06/2022, às 11:00 horas, nesta Comarca de Piraju, na sala de audiências, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito, Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) LUCAS DADALTO SAHÃO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento.

PRESENCAS / AUSÊNCIAS

Aberta a audiência com as formalidades legais, compareceram o Promotor de Justiça, Dr. Cristiano dos Santos Barros; ausente o réu GUILHERME AFONSO DOS SANTOS, acompanhado do(a) Defensor(a), Dr(a). Carlos Alberto Bernabe, bem como a(s) testemunha(s) Dino César Barreto.

ASSENTADA

Abertos os trabalhos, pelo MM. Juiz de Direito foi dada a palavra ao(a) Defensor(a) do(a) réu(ré) para que se manifestasse em defesa preliminar e por ele(a) foi apresentada defesa nos seguintes termos: MM. Juiz, reitero os termos da defesa preliminar apresentada nos autos. A seguir pelo(a) MM Juiz(a) foi proferida a seguinte decisão: Há nos autos elementos que possibilitam o recebimento da denúncia, visto que há indícios da existência dos supostos delitos e da sua autoria assim, RECEBO A DENÚNCIA ofertada contra GUILHERME AFONSO DOS SANTOS. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte decisão: O réu, regularmente citado e intimado para participar da presente audiência (pág. 92), deixou de comparecer, assim, nos termos do artigo 367 do CP, decreto sua revelia. Ato contínuo, passou o(a) MM. Juiz(a) a inquirir a testemunha Dino César Barreto. Pelo Promotor de Justiça foi dito que desistia da oitiva da testemunha Waldir, o que foi homologado pelo MM. Juiz(a). Em seguida foi realizado o interrogatório do(s) réu(s). As ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia será oportunamente disponibilizada nos autos. Em seguida, não havendo mais provas a produzir, o(a) MM. Juiz(a) declarou encerrada a instrução, dando-se a palavra às partes para se manifestarem em alegações finais.

DEBATES

Dada a palavra, primeiramente, ao(à) DD. Representante do Ministério Público, e depois ao (à) Defensor(a), as alegações finais foram colhidas e gravadas em sistema audiovisual.

SENTENÇA

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida sentença nos seguintes termos: Vistos. Relatório dispensado (art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/1.995). Fundamento e decido. O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Passo à análise do mérito da causa. A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 1/2), pelo termo circunstanciado (fls. 1/2), pelo auto de exibição e apreensão da droga (fl. 6) e pelos laudos de constatação preliminar (fl. 7) e de exame químico-toxicológico (fls. 13/15), cujo resultado foi positivo para maconha (tetrahidrocannabinol), droga proscriita pela Portaria ANVISA 344/1998 e alterações posteriores. A autoria também é certa, despontando da prova oral produzida nos autos. O policial militar Dino Cesar Barreto, ouvido como testemunha, narrou os fatos em conformidade com a denúncia. Relatou que faziam patrulhamento de rotina pela Avenida João Henrique Soares, Município de Sarutaiá, e avistaram o acusado, que apresentou atitude suspeita diante da presença da viatura policial; em abordagem, encontraram no bolso da bermuda do réu três porções de maconha; em consulta ao Prodesp, constatou que o increpado estava na situação "procurado"; indagado, o imputado admitiu ser usuário de drogas (fl. 4 e mídia da audiência). Como se vê, o seguro, claro e congruente testemunho do agente público, que tem eficácia probatória amplamente reconhecida pela jurisprudência de há muito consolidada pelos tribunais superiores - desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu (como na espécie, até porque não o conhecia) -, forma quadro probatório convincente e bastante para lastrear o edito condenatório. A par disso, a defesa não comprovou fato impeditivo ou extintivo da pretensão punitiva (inexistência material do fato típico), cujo ônus lhe incumbia (art. 156 do CPP), de sorte que não vinga a tese da absolvição por falta de provas da autoria. Quanto à qualificação jurídico-legal dos fatos, atento ao objeto material do delito (diminuta quantidade de maconha, embalada em 3 porções), ao desvalor da ação (local

e condições em que se desenvolveu a conduta) e ao próprio agente do fato (circunstâncias sociais e pessoais não desabonadoras, inexistência de maiores informações sobre a conduta e ausência de antecedentes do agente, ao menos por ocasião da prática dos fatos ora sob apuração), critérios que devem ser sopesados pelo juiz no mister de determinar se a droga destinava-se, ou não, ao consumo pessoal (art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006), tenho que nada aponta para a traficância, de modo que a conduta se amolda, mesmo, à definição jurídica estampada na denúncia (art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006). Também não há que se falar em inconstitucionalidade da criminalização do porte de drogas para consumo pessoal, tampouco em atipicidade da conduta, sob a argumentação de que se está diante de autolesão. Cuida-se de crime vago, que vulnera bem jurídico difuso (saúde pública) e tem como sujeito passivo a coletividade, e não o próprio indivíduo que consome drogas, não se cogitando, pois, de autolesão, na esteira do que leciona RENATO BRASILEIRO DE LIMA, invocando a jurisprudência relativa ao tema: Apesar da despenalização produzida pela Lei nº 11.343/06 em relação ao porte de drogas para consumo pessoal, afastando-se a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade para o usuário de drogas, a legislação brasileira ainda incrimina a conduta do indivíduo que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Para muitos, essa opção pela punição do porte de drogas para consumo pessoal seria incompatível com a Constituição Federal, seja por violar o direito à intimidade e à vida privada (CF, art. 5º, X), seja por se mostrar incompatível com o princípio da ofensividade. (...). A despeito desse entendimento, ainda prevalece a orientação no sentido de que a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal não é incompatível com a Constituição Federal. Por mais que o agente traga a droga consigo para consumo pessoal, não se pode perder de vista que a sua conduta coloca em risco a saúde pública, porquanto representa um risco potencial à difusão do consumo de drogas. De mais a mais, mesmo que indiretamente, outros bens jurídicos além da saúde pública são lesionados em virtude dessa conduta. Com efeito, não é incomum que o usuário-dependente pratique outros crimes para sustentar seu vício. Ademais, a aquisição de drogas por parte do usuário serve como forte estímulo para a prática do tráfico de drogas. Noutro giro, por mais que seja verdade que a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal não venha surtindo o efeito desejado, nem por isso se pode cogitar da possibilidade de renunciarmos à tutela do direito penal para coibir tal conduta. Fosse assim, condutas delituosas diversas como homicídios, latrocínios e roubos também deveriam ser descriminalizadas, porquanto a utilização do Direito Penal como instrumento para coibir tais condutas delituosas também não vêm surtindo os efeitos desejados, infelizmente. Prova disso, na lição de Mendonça e Carvalho, é a situação das “Cracolândias” espalhadas por todo o território nacional, onde grupos de cidadãos transformam-se em flagelados por conta da dependência química gerada pelo uso descontrolado de drogas, passando a praticar uma infinidade de crimes de modo a sustentar o vício. Para os autores, “embora se saiba que, para essas hipóteses, é mais útil a intervenção estatal a partir de políticas públicas voltadas ao tratamento e principalmente à reinserção social dos dependentes, visando trazê-los de volta ao seio social, não se pode privar o Estado de todos os meios preventivos e repressivos dessa verdadeira catástrofe social, dentre os quais a perspectiva de punição penal ao usuário”. De todo modo, convém destacar que a matéria deve ser apreciada em breve pelo Supremo Tribunal Federal. Consoante notícia de 22 de dezembro de 2011, o Plenário do Supremo admitiu a existência de repercussão geral em Recurso Extraordinário (RE 635.659) no qual um acusado foi condenado à pena de 2 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade pelo Juizado Especial Criminal de Diadema/SP. A Defensoria Pública de São Paulo questiona a constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas à luz do direito à intimidade e à vida privada e diante do princípio da ofensividade. (Legislação criminal especial comentada: volume único – 9. ed. – Salvador: JusPODIVM, 2021, pp. 1035/1036). Como o aludido julgamento do RE 635.659 ainda não foi concluído, e por se tratar de análise em controle difuso de constitucionalidade, ainda que seja reconhecida a incompatibilidade do dispositivo com a ordem constitucional, é necessário que haja suspensão da norma pelo Senado

Federal (art. 52, X, da CF), caso em que, somente então, a decisão vinculará juízes e Tribunais, pois o Pretório Excelso tem afastado a tese da abstrativização do controle difuso. De resto, descabe a aplicação do princípio da insignificância à espécie. Apesar de a quantidade de droga apreendida não ser considerável, esta circunstância já serve de base para a configuração do crime em comento; se houvesse grande quantidade do estupefaciente, estar-se-ia, por suposto, diante do crime de tráfico de drogas. Ademais, pela própria natureza do delito de posse de droga para consumo pessoal – crime de perigo abstrato –, afigura-se inviável o acolhimento da tese da insignificância, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância (RHC n. 34.466/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 27/5/2013). 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 620033 MG 2014/0317728-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015); e RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ - RHC: 37094 MG 2013/0118921-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2014). Logo, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, e inexistindo causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, tampouco extintivas da punibilidade, a conduta é típica e antijurídica, incidindo, pois, as sanções cominadas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. O preceito secundário da norma penal descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 prevê a possibilidade de o magistrado aplicar as seguintes penas: advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo (incisos I, II e III). Tais penas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como ser substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor (art. 27 da mesma lei). Nessa tarefa, o aplicador deve levar em consideração a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), sem embargo da utilização subsidiária do quanto disposto no art. 59 do CP. No tocante à duração das penas, a advertência é imediata e instantânea, ao passo que as outras duas serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses (art. 28, § 3º, da LD), tratando-se de acusado primário, ou de 10 (dez) meses, tratando-se de reincidente (art. 28, § 4º, da LD). Consoante entendimento recente do STJ, externado pela 6ª Turma no REsp 1.771.304-ES, sob a relatoria do eminente Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 10.12.2019, ao qual me filio, a reincidência, para fins de aplicação do art. 28, § 4º, da Lei nº

11.343/2006, com a consequente possibilidade de aplicação das penas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses, é apenas a específica. Assentou a Corte Superior de Justiça que a melhor exegese, segundo a interpretação topográfica, essencial à hermenêutica, é a de que os parágrafos em foco não são unidades autônomas, estando vinculados ao caput do artigo a que se referem. Joeirados esses critérios, observo que a ínfima quantidade de drogas não enseja maior reprovação penal, e não há informações precisas sobre a personalidade e conduta social do agente. Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, grau de reprovabilidade da conduta, é normal à espécie. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, LVII da CF, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, seja pelo decurso do prazo de 5 anos após a extinção da pena (CP, art. 64, I), seja pela condenação anterior ter sido lançada em consequência de crime militar próprio ou político (CP, art. 64, II), seja, ainda, pela peculiaridade de o novo crime ter sido cometido antes da condenação definitiva por outro delito, consoante consagrado pela jurisprudência pátria. In casus, trata-se de réu primário (fl. 26). Os motivos não merecem maior reprovação, por serem ínsitos à espécie criminosa. As circunstâncias e as consequências do crime não destoaram do ordinário. Não há elementos nos autos para se avaliar a conduta social e a personalidade do réu. Por fim, em razão da natureza do crime, não há que se falar em comportamento da vítima. Entendo que a medida de advertência, aplicada de forma isolada, não surte o efeito esperado, de maneira que não é suficiente para alcançar a finalidade da norma penal. Reputo ser mais adequada à prevenção e repressão do delito, dentre as duas outras cominadas pelo art. 28 da LD, a medida de prestação de serviços à comunidade. No tocante à duração da sanção penal, sendo o réu primário, na esteira da motivação supra, aplica-se o art. 28, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, a ditar a aplicação da penalidade pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses. Considero exagerada a aplicação da pena no patamar máximo de 5 (cinco) meses, de modo que lhe aplico a medida pelo prazo de 2 (dois) meses, adotando solução de meio-termo. Consigno que o descumprimento injustificado da medida imposta sujeitará o condenado à admoestação verbal e, sucessivamente, ao pagamento de multa, tudo na forma do § 6º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado GUILHERME AFONSO DOS SANTOS, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 (dois) meses. Diante da característica da pena aplicada, assiste ao réu o direito de recorrer em liberdade. Condeno o sentenciado também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do CPC. Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do CPP), porque se está diante de crime vago, e não houve pedido expresso da acusação nesse particular. Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Expeça-se a competente certidão de honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado: (a) determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06; (b) caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25, do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ); (c) comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; (d) expeça-se a guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente,

observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017; (e) lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD; e (f) ofícios de praxe; Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa. Ao final da audiência, na presença dos Defensores e do(a) Promotor(a) de Justiça, pelo(a) MM. Juiz(a) foi lido o dispositivo da sentença. Após a leitura, o(a) MM. Juiz(a) indagou às partes acerca da intenção de recorrer, sendo que, pelos Defensores do(a) ré(u) e pelo(a) Promotor(a) de Justiça foi dito que não pretendem recorrer da sentença, devendo ser certificado o trânsito em julgado da sentença. Nada mais. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Lido e achado conforme. Eu, Fabiano Mazziotti José), Chefe de Seção Judiciário, digitei.